

裁判字號：最高行政法院 102 年度裁字第 266 號 行政裁定 精選裁判

案由摘要：刑事

裁判日期：民國 102 年 03 月 07 日

要 旨：按行政訴訟法第 5 條所謂依法申請之案件，係指人民依據法令之規定，有向機關請求就某一特定具體之事件，為一定處分之公法權利者而言。又法令如僅係規定行政機關之職權行使，因其並非賦予人民有公法上請求行政機關為行政處分之權利，人民之請求行政機關作成行政處分，性質上僅是促使行政機關發動職權，乃屬建議、舉發之陳情性質，並非屬於「依法申請之案件」。

（裁判要旨內容由法源資訊撰寫）

被引用數：0 次

最高行政法院裁定 102年度裁字第266號

抗 告 人 劉清文

上列抗告人因與相對人高雄市美濃區公所間刑事事件，對於中華民國101年12月10日高雄高等行政法院101年度訴字第450號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主 文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

- 一、按抗告法院認抗告為不合法或無理由者，應為駁回抗告之裁定。
- 二、本件原裁定以：本件抗告人依刑事訴訟法第241條規定，於101年4月19日以「請求書（兼檢舉書）」請求相對人責成所屬職掌宗教禮俗業務之公務員應依偽造文書等罪，對系爭祭祀公業管理人劉庚龍，理事劉秋雄、劉新治、劉勝智，監事主席劉秋吉，監事劉初雄、劉志安、劉秀喜、劉進春等9人，向臺灣高雄地方法院檢察署為告發，因抗告人並無請求相對人所屬公務員為告發之公法上權利，是抗告人前開請求，其作用應僅在促使相對人注意發動告發之職權而已，並非屬行政訴訟法第5條所稱之「依法申請」之案件，且亦無應於法令所定期間內應作為而不作為，或對於抗告人依法申請之案件予以駁回之情事可言。是以，抗告人依刑事訴訟法第241條規定請求相對人應責成其所屬職掌宗教禮俗業務之公務員告發犯罪嫌疑者，縱令相對人未依其請求命所屬公務員為告發行為，然其既非抗告人「依法申請」之案件，自不生所謂相對人應於法令所定期間內應作為而不作為之問題，抗告人提起課予義務訴願及課予義務訴訟即與訴願法第2條第1項及行政訴訟法第5條第1項規定之要件不符。訴願決定以相對人101年4月19日高市美區民字第10130607500號函為觀念通知，並非行政處分為由，而為訴願不受理之決定，理由雖有不同，惟結論並無不合，仍應予以維持；抗告人復提起本件行政訴訟，核與課予義務訴訟之要件不合，且無從補正等語

，乃駁回抗告人之訴。

三、抗告意旨略謂：刑事訴訟法第241條規定之「應為告發」，乃強制作為義務之規定，亦即只要公務員因執行職務知有犯罪嫌疑，無待人民對其為一定之作為請求，即應有告發之義務，別無推諉之餘地，方符該條規定之旨趣及立法意旨，此揆諸法務部99年7月13日法檢字第0999027790號函釋及最高法院74年度台上字第3644號判決要旨即明，亦足證原審認事用法之顛預及法律見解之違誤；又觀諸臺北市政府訴願審議委員會0000-00-00發布新聞略謂「某整形外科診所醫師……原手術紀錄不實部分，涉嫌刑法第215條規定業務上文書登載不實罪，另依刑事訴訟法第241條規定，移請臺灣臺北地方法院檢察署偵辦……」則本件訴願機關應依刑事訴訟法第241條規定，移請臺灣高雄地方法院檢察署偵辦，始屬正辦；另有鑑於媒體偶有報導普通法院對民事起訴案件，於審理後，就涉嫌刑事犯罪部分，移請該管法院檢察署偵辦之情事，是本件可否建請原審逕予移送臺灣高雄地方法院檢察署偵辦，以落實政府節能減碳措施云云，為此請求廢棄原裁定。

四、本院查：

（一）按「（第1項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間內應作為而不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。（第2項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」行政訴訟法第5條定有明文。是依上開規定提起課予義務訴訟，係以有「依法申請之案件」存在為要件，否則起訴不備要件。所謂「依法申請之案件」，係指人民依據法令之規定，有向機關請求就某一特定具體之事件，為一定處分之公法權利者而言；所謂「應作為而不作為」，係指行政機關對於人民之申請負有法定作為義務，卻違反此一作為義務而言。是法令如僅係規定行政機關之職權行使，因其並非賦予人民有公法上請求行政機關為行政處分之權利，人民之請求行政機關作成行政處分，性質上僅是促使行政機關發動職權，乃屬建議、舉發之陳情性質，並非屬於「依法申請之案件」。在此情形，人民以行政機關對其請求，於法定期間內應作為而不作為，或予以駁回而提起課予義務訴訟，因無「依法申請之案件」存在，其訴訟即不備起訴要件，而不合法，應依行政訴訟法第107條第1項第10款予以駁回。

（二）次按刑事訴訟法第241條規定：「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。」乃係基於公益之考量，要求公務員於執行職務中，明知他人有犯罪嫌疑者，負有舉發犯罪之義務，促使國家追訴機關發動偵查，惟此非僅憑有利害關係之一方任意指陳即有告發義務，且並未賦予人民有請求公務員對犯罪嫌疑人告發之公法上權利。是原裁定以抗告人之請求，應僅在促使相對人注意發

動告發之職權而已，並非屬行政訴訟法第5條所稱之「依法申請」之案件，且亦無應於法令所定期間內應作為而不作為或對於抗告人依法申請之案件予以駁回之情事，抗告人提起課予義務訴訟，即與行政訴訟法第5條第1項規定之要件不合，且無從補正，爰以裁定駁回之，經核並無違誤。抗告意旨援引上開法務部函釋及最高法院判決意旨，主張相對人有為告發之作為義務云云，核屬其一己主觀見解，並無可採；其餘抗告意旨仍執陳詞，指摘原裁定違法，求予廢棄原裁定，難認有理由，應予駁回。

五、據上論結，本件抗告為無理由。依行政訴訟法第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 102 年 3 月 7 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 黃 合 文

法官 鄭 忠 仁

法官 帥 嘉 寶

法官 林 惠 瑜

法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 102 年 3 月 8 日

書記官 張 雅 琴

資料來源：自司法院網站選擇編輯

歷審裁判：高雄高等行政法院 101 年度 訴 字第 450 號裁定 (101.12.10)

高雄高等行政法院 101 年度 訴 字第 450 號裁定 (102.01.04)

最高行政法院 102 年度 裁 字第 266 號裁定 (102.03.07)

相關法條：訴願法 第 2 條 (101.06.27)

行政訴訟法 第 5、107 條 (102.01.09 有非現行條文)

中華民國刑法 第 215 條 (100.11.30 有非現行條文)

刑事訴訟法 第 241 條 (102.01.23)

司法判解：最高法院 74年台上字第 3644 號 刑事

類案推薦：最高法院 83 年度台抗字第 269 號 刑事 (83.06.30)

最高行政法院 106 年度裁字第 441 號 裁定 (106.04.13)

最高法院 101 年度台上字第 402 號 刑事判決 (101.01.19)

最高法院 94 年度台上字第 388 號 刑事判決 (94.01.21)

最高法院 107 年度台上字第 2347 號 刑事判決 (107.07.04)